

刑法
No178

R4-11

(配点: 2)

月 日

月 日

共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 刑法第60条における「実行」とは、基本的構成要件の実現に向けた行為に限定され、予備行為はこれに含まれないから、予備罪の共同正犯は成立しない。
2. 実行共同正犯の成立に必要な各関与者間の意思連絡は、明示的なものだけではなく黙示的なものも含むが、共謀共同正犯においては、明示的な意思連絡が必要であり、黙示的な意思連絡では足りない。
3. ある犯罪が成立するについて当然予想され、その成立のために欠くことができない関与行為について、これを正犯として処罰する規定がない場合であっても、関与を受けた側の可罰的な行為の教唆又は幫助として処罰されることは当然である。
4. 既に特定の犯罪の実行を確定的に決意している者に対してその実行を勧め、これによってその者の決意が強固になった場合、幫助犯は成立し得るが、教唆犯は成立しない。
5. 犯行に必要な用具を第三者を介して正犯に提供した場合、正犯の犯行を間接的に幫助したことになるが、間接教唆と異なり、間接幫助を処罰する明文の規定が存在しないため、幫助犯は成立しない。

No178

共 犯

正答率

R4-11

正 解

4

69%

1 誤っている

本記述は、予備罪の共同正犯は成立しないとしている点で、誤っている。

最決昭 37.11.8 (百選 I 80 事件)。判例は、A を殺害する計画を立てた Y が、被告人 X に青酸カリの入手を依頼したところ、X はそれを承諾した上で青酸カリを入手して、Y に手渡したが、Y は青酸カリを使用しなかったという事案において、殺人予備罪の共同正犯 (201 条、60 条) が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、60 条の「実行」には修正された構成要件に該当する行為も含むということを挙げている。したがって、予備罪の共同正犯は成立する。

2 誤っている

本記述は、共謀共同正犯においては、明示的な意思連絡が必要であり、黙示的な意思連絡では足りないとしている点で、誤っている。

①最判昭 23.11.30、②最決平 15.5.1 (百選 I 76 事件)。本記述前段について、実行共同正犯の場合、判例①は、「明示の意思の表示が無くても暗黙にでも意思の連絡があれば共謀があったといえる」としている。よって、実行共同正犯の成立に必要な各関与者間の意思連絡は、明示的なものだけではなく黙示的なものも含む。したがって、本記述前段は正しい。

本記述後段について、共謀共同正犯の場合、判例②は、暴力団組長である被告人が自己のボディガード A らのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うかが問題となった事案において、被告人には本件けん銃等の所持について、A らとの間に共謀共同正犯が成立するとしている。その理由として、判例は、「被告人は、A らに対してけん銃等を携行して警護するように直接指示を下さなくても、A が自発的に被告人を警護するために本件けん銃等を所持していることを確定的に認識しながら、それを当然のこととして受け入れて認容していたものであり、そのことを A らも承知していた……被告人と A らとの間にけん銃等の所持につき黙示的に意思の連絡があったといえる。そして、A らは被告人の警護のために本件けん銃等を所持しながら終始被告人の近辺にいて被告人と行動を共にしていたものであり、彼らを指揮命令する権限を有する被告人の地位と彼らによって警護を受けるという被告人の立場を併せ考えれば、実質的には、正に被告人が A らに本件けん銃等を所持させていたと評し得る」ということを挙げている。よって、共謀共同正犯において、必ずしも明示的な意思連絡が必要ではなく、黙示的な意思連絡で足りる場合がある。したがって、本記述後段は誤っている。

3 誤っている ★

本記述は、ある犯罪が成立するについて当然予想され、その成立のために欠くことができない関与行為について、これを正犯として処罰する規定がない場合であっても、関与を受けた側の可罰的な行為の教唆又は幫助として処罰されることは当然であるとしている点で、誤っている。

最判昭 43.12.24 (百選 I 99 事件)。判例は、弁護士でない者に、自己の法律事件の示談解決を依頼し、これに報酬を与えもしくは与えることを約束した事案において、弁護士法 72 条違反の罪の教唆犯は成立しないとしている。その理由として、判例は、「同法 72 条の規定は、法律事件の解決を依頼する者が存在し、この者が、弁護士でない者に報酬を与える行為もしくはこれを与えることを約束する行為を当然予想しているものということができ、この他人の関与行為なくしては、同罪は成立し得ないものと解すべきである。ところが、同法は、右のように報酬を与える等の行為をした者について、これを処罰する趣旨の規定をおいていないのである。このように、ある犯罪が成立するについて当然予想され、むしろそのために欠くことができない関与行為について、これを処罰する規定がない以上、これを、関与を受けた側の可罰的な行為の教唆もしくは幫助として処罰するこ

とは、原則として、法の意図しないところと解すべきである」ということを挙げている。

4 正しい

大判大6.5.25により、本記述は正しい。

判例は、助言によって他人の犯罪に加功した場合、その助言が犯行の故意を決定させたときは教唆犯であり、単に既発の犯意を強固ならしめたときは幫助犯であるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、精神的幫助は、既に犯行を決意している者に助言や激励を行うことによってその決意を強固にし、犯罪の実行を容易にするものであるのに対し、教唆は、未だ犯罪の実行を唆して新たに犯行を決意させる点で異なるということを挙げている。

5 誤っている

本記述は、間接幫助の場合、幫助犯は成立しないとしている点で、誤っている。

最決昭44.7.17（百選186事件）。61条2項は、教唆犯を教唆する間接教唆を処罰する規定であるが、幫助犯を幫助する間接幫助を処罰する明文の規定は存在しない。しかし、判例は、被告人が、Aまたはその得意先の者において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、わいせつ映画フィルムを右Aに貸与し、Aからその得意先であるBに右フィルムが貸与され、Bにおいてこれを映写し十数名の者に観覧させて公然陳列するに至ったという事案において、被告人は正犯たるBの犯行を間接に幫助したものとして、従犯の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、因果的共犯論の見地から、正犯を間接的に幫助する者は、結果との因果関係が認められるため、正犯を直接幫助する者と同様、62条1項の適用対象となるということを挙げている。したがって、犯行に必要な用具を、第三者を介して正犯に提供した場合、幫助犯は成立し得る。